

1501375-74.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Vilibor Breda

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... encontrados estavam sob seu poder para fins de tráfico e que Flávio teria ido até o local para adquirir a droga. Sendo assim, o conjunto probatório, neste momento processual é incapaz de provar que Flávio era o detentor da droga.

Diante o quadro apresentado, muito embora o tráfico hodiernamente represente uma das mais inquietantes expressões da criminalidade, a solução à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

2ª Vara

Praça da Bandeira, s/n, Santa Isabel - SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501375-74.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501375-74.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO DE JESUS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudia Vilibor Breda

VISTOS

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra MARCOS APARECIDO DOS SANTOS e FLÁVIO DE JESUS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, na data de 22 de maio de 2021, no período noturno, na Rua Japão, nº 276, Residencial São João, na cidade e Comarca de Santa Isabel, MARCOS APARECIDO DOS SANTOS e FLÁVIO DE JESUS SANTOS, com unidade de

desígnios, consciência e vontade, traziam consigo e guardavam, para inequívoco fim de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes em: 111 (cento e onze) porções de Tetrahydrocannabinol – THC (maconha); 83 (oitenta e três) porções de cocaína e 22 (vinte e duas) porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; laudo de constatação preliminar de fls. 13/18; e laudo de exame químico-toxicológico).

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 01) e, após audiência de custódia realizada em 23 de maio de 2021, tiveram suas prisões preventivas decretadas (fls. 51/53).

Relatado o Inquérito Policial (fls. 06/08) a n. Promotora de Justiça da comarca de Arujá ofereceu denúncia às fls. 82/85, e requereu a redistribuição dos autos ao juízo competente, oportunidade em que a denúncia foi ratificada pelo n. Promotor de Justiça da Comarca de Santa Isabel (fls.93).

Na Decisão de fls. 95/96, notificaram-se os acusados nos termos do artigo 55, caput, e §1º da Lei 11.343/2006.

Concretizados os atos citatórios os advogados dativo e constituído ofertaram as respostas escritas, reservando-se no direito de se pronunciar no decorrer da instrução (fls. 128/129 e 135/136).

Revisando e decidindo acerca da manutenção preventiva dos Acusados, com base na Lei 13.964/2019, manteve-se a prisão dos Réus, haja vista que os motivos que a ensejaram permaneceram inalterados (fls. 130/131 e 166/167).

Preenchendo os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade houve o recebimento das respostas a acusação e ratificada a denúncia, bem como o processo foi saneado em 08 de outubro de 2021, oportunidade em que se designou audiência de instrução e julgamento para o dia 13 dezembro de 2021 às 15h30min por meio da ferramenta Microsoft Teams (fls. 144/146).

Iniciados os trabalhos em audiência, através do sistema de gravação em áudio e vídeo, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e policiais militares Ednaldo Barbosa Santana e Virgílio Camilo Caraça Junior, bem como, procederam-se aos interrogatórios dos Réus. Restou determinado a expedição de mandado de constatação a fim de verificar o endereço do acusado antes dos fatos e o laudo toxicológico definitivo. Por fim, não havendo mais provas a serem produzidas os debates orais foram convertidos em memoriais escritos (fls.173/175).

Em seus memoriais escritos, o nobre Promotor de Justiça, requereu que a ação penal seja julgada procedente, condenando MARCOS APARECIDO DOS SANTOS e FLAVIO DE JESUS SANTOS como incurso no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 186/196).

Rechaçando a pretensão ministerial a nobre defesa do réu Marcos em suas alegações finais pleiteou a redução da pena seguindo os parâmetros do §4º do artigo 33 da Lei 11.343, haja vista que a tese de defesa de negativa de autoria ficou prejudicada em virtude da confissão espontânea do réu (fls. 199/203). Em relação ao réu Flávio, em suas alegações finais pleiteou a n. advogada dativa absolvição do acusado pela ausência de provas e, em caso de condenação, pugnou pela aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343, havendo assim, a possibilidade de redução da pena de 1/6 até 2/3 (fls. 218/223).

Ao lado da prova oral colhida em juízo, acostou-se o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 5/8); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12); Laudo de Constatação Provisória (fls. 13/18); e Laudo Químico Toxicológico (fls. 181/183).

Folhas de antecedentes acostadas às fls. 103/104 e 105/109 e Certidões de feitos criminais juntadas às fls. 157/160 e 161.

Vieram os autos conclusos para a sentença.

Este é, em apertado resumo, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A DENÚNCIA É PROCEDENTE EM PARTE

Cuida-se de ação penal em que os réus Marcos e Flavio se encontram processados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, fato este corrido em 22 de maio de 2021.

O aumento desenfreado do consumo de drogas no mundo, bem como o surgimento contínuo de novos entorpecentes, é um sinal da decadência humana merecendo, pois, total repulsa e repressão.

A natureza tóxica das substâncias apreendidas e a consequente materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pela prova oral colhida sob o prisma do contraditório, o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos, o Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação e o Laudo Químico Toxicológico.

O exame toxicológico não deixou dúvidas sobre a natureza das substâncias apreendidas, porquanto as análises químicas e físico-químicas realizadas no material revelaram resultado positivo para a substância COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), droga esta popularmente conhecida como maconha, trazendo elementos mínimos necessários à avaliação judicial da materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ao lado da existência material do crime, no tocante as autorias, buscando a salvaguarda da ampla defesa e contraditório, passo a analisar a as provas em relação a cada um dos denunciados.

DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO RÉU MARCOS.

Iniciando a análise da prova da acusação temos o depoimento do Policial Militar Ednaldo Barbosa Santana, também responsável pelo flagrante, disse se recordar dos Réus por conta dos fatos. Contou que estava fazendo ronda pelo local, que já era conhecido pela venda de entorpecentes e que os acusados no momento em que avistaram a viatura tentaram fuga dispensando objetos pelo chão. Com o Réu Marcos foi encontrado um celular, a carteira e um alvará de soltura, bem como havia dispensado uma sacola branca com entorpecentes e dinheiro em notas trocadas. Embora Flavio não estivesse com nada de ilícito também dispensou uma sacola com entorpecentes. Os Réus foram abordados separadamente e atribuíram à culpa ao outro. Além dos policiais não havia civis passando pelo local no momento da abordagem.

Apresentou em juízo o Policial Militar Virgílio Camilo Caraça Junior em versão harmônica a de seu parceiro, recordando-se dos réus mediante aos fatos. Afirmou que estava em patrulhamento no local conhecido pelo tráfico de entorpecentes e quando avistaram os Réus esses tentaram se evadir e dispensando dois objetos no chão. Na abordagem pessoal de Marcos localizaram um celular, um alvará de soltura e uma carteira e na sacola que havia dispensado tinha drogas e a quantia de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Na revista pessoal de Flavio não encontraram nada de ilícito, porém na sacola que tinha dispensado acharam entorpecentes. Quando questionados isoladamente, um acusou o outro pela traficância.

Em seguida, fechando a prova oral desenrolou-se a autodefesa do acusado Marcos. No seu interrogatório o réu Marcos, disse que tem 24 anos e já foi processado antes por tráfico de drogas e assalto a mão armada no ano de 2016. Tem uma filha de sete meses de idade. Não faz uso de drogas e nem de bebidas alcoólicas. Conheceu o correú naquela noite e não tinha amizade com ele. Afirma que estava traficando em virtude da situação difícil pela qual estava passando, haja vista que tinha uma filha recém-nascida há 10 dias e sem emprego. Afirma que o Réu Flávio não estava traficando, bem como não dispensou nenhuma sacola, só estava no local para adquirir os entorpecentes e quando avistaram a viatura correram.

Por sua vez, em seu interrogatório o réu Flávio afirma ter 23 anos e nunca foi processado antes ou respondeu por atos infracionais. Afirma ser usuário de drogas. Não conhecia o Réu Marcos. Estava no local apenas para adquirir droga e quando viu os policiais se desesperou e correu junto com Marcos. Só tinha em mãos um isqueiro. Nunca tinha sido abordado antes pelos policiais, até mesmo porque era novo na cidade. Não sabe o porquê os policiais comentaram que teria dispensado uma sacola. Levou um soco no peito e Marcos um tapa na cabeça.

É o cerne do acervo probatório angariado ao feito.

Verifica-se da prova oral que o denunciado Marcos confessou a traficância, justificando a venda de drogas para o sustento de sua filha recém-nascida.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos militares que desfilaram no palco do contraditório trazendo harmonia e certeza para a condenação, conforme preconiza o artigo 197 do Código de Processo Penal, eis que não tem precedência hierárquica sobre as demais provas.

Se não bastasse isso, a forma de acondicionamento das drogas dispensadas pelo acusado, o encontro de papel moeda na busca pessoal do réu Marcos e um telefone celular e, ainda, o palco do flagrante- local conhecido pelo tráfico de drogas, somado a confissão do acusado, tornam inviável a desclassificação para o crime de uso ou a absolvição.

Frise-se, em reforço, que apesar da configuração do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas não exigir qualquer ato de venda de droga, bastando, como na espécie, que o guarde ou tenha em depósito a substância entorpecente com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, fica no presente caso certa a traficância pelo transporte da droga, conforme foi exposto pelo réu em juízo, uma vez que confidenciou ter abandonado a sacola com entorpecentes.

## II- DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO RÉU FLAVIO

Em que pese à gravidade do delito imputado ao acusado, imperativo o édito absolutório em seu favor, como bem registrado pela nobre defensora, porquanto, o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, já que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em seu poder e a afirmação de que houve a dispensa da segunda sacola pelo acusado partiu apenas da fala dos policiais e foi negado pelo correú Marcos.

Também não parece de todo pueril acreditar que por ter sido o flagrante lavrado no período noturno e os acusados estarem juntos, não houve a visualização exata se a dispensa das sacolas se deu por ambos ou um deles apenas. Logo, a dúvida favorece o réu Flavio, na medida em que o segundo denunciado assumiu, na integralidade, a responsabilidade penal e não haveria motivo plausível para Marcos inocentar Flavio, pessoa que não era seu convívio, vindo a ter o primeiro contato quando dos fatos.

Também gravita em favor do réu Flavio neste momento de decisão de seu destino processual o fato de não registrar antecedentes criminais ou qualquer passagem que desabonasse sua conduta.

Logo, sem desprestigiar a fala dos policiais, uma vez que nenhum entorpecente foi encontrado com o réu Flavio e, ainda, não tendo sido afirmado nos depoimentos de forma objetiva que o réu realizava qualquer das atividades descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, ainda, admitindo-se uma falha na visualização da dispensa das sacolas, a dúvida favorece o réu.

Repita-se, mesmo que os depoimentos dos Policiais Militares sejam concisos, restam dúvidas se de fato o réu Flavio teria dispensado a sacola plástica com entorpecentes. Ademais, o réu Marcos, desconhecido de Flávio até então, afirmou em audiência que os ilícitos encontrados estavam sob seu poder para fins de tráfico e que Flávio teria ido até o local para adquirir a droga. Sendo assim, o conjunto probatório, neste momento processual é incapaz de provar que Flávio era o detentor da droga.

Diante o quadro apresentado, muito embora o tráfico hodiernamente represente uma das mais inquietantes expressões da criminalidade, a solução à realidade processual é a absolutória, porquanto, para uma condenação, não bastam suposições, mas prova cabal da participação delitiva. Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o que realmente ocorreu o acusado deve ser absolvido com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.

O clamor público, por si só, não pode induzir a uma condenação, a pretexto de se dar uma resposta aos jurisdicionados. Vilipendiaria, sim, o Princípio do In Dubio Pro Reo.

Corrobora-se, portanto, ser apenas procedente e certa a condenação em relação ao acusado MARCOS em relação ao crime de tráfico, autorizando-se prosseguir agora para a aplicação da pena obedecendo ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Iniciando a aplicação da pena em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA BASE acima do mínimo legal, isto é, 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 580 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em razão da diversidade e quantidade da droga (144.62 gramas de TETRAHIDROCANNABINOL (THC)), (47.31 gramas de COCAINA) e (2.21 gramas de CRACK), colocando em maior risco a saúde pública.

Outrossim, se não fosse a astúcia dos policiais militares, pela quantidade da droga apreendida o tráfico realizado pelo réu alcançaria diversos usuários, na maioria jovens

Na segunda fase da aplicação da pena a confissão do réu Marcos, uma atenuante, confronto com a agravante da reincidência e as duas acabam se aniquilando, não sofrendo alteração a pena base.

Na terceira fase da aplicação, deixo de aplicar a redução prevista na lei de drogas, pois o réu é reincidente, tornando-se DEFINITIVA A PENA EM 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 580 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em razão da diversidade e quantidade da droga

A reincidência impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis.

O regime inicial pelo fato do réu ser reincidente deve-se iniciar a partir do regime FECHADO e, ainda, em face da natureza do crime que revela a periculosidade concreta do agente. O tráfico provoca instabilidade em inúmeros lares, exigindo, portanto, uma resposta penal mais enérgica, além de fomentar um poder paralelo que desafia e se opõe à sociedade organizada, destrói pessoas e famílias, aniquila o

futuro dos jovens.

Ainda, não se desconhece o teor das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, mas no caso concreto, reincidente em tráfico, não se revela adequado regime mais brando. Quanto ao artigo 387, § 2º do CPP, embora o réu se encontre preso desde 23/05/2021, a alteração do regime prisional não é devida, quer porque não cumpriu 60% da pena segundo na nova legislação (o tráfico é crime hediondo por equiparação e o réu é reincidente), quer porque a mudança para o aberto exige o exame de aspectos que não constam dos autos (comportamento do agente na prisão, por exemplo), de modo que caberá ao Juiz das Execuções, analisar a questão.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENUNCIA PARA O FIM DE ABSOLVER O RÉU FLAVIO DE JESUS SANTOS, filho de Edivaldo Ribeiro dos Santos e Luzinete Maria de Jesus, natural de Itarantim- BA, portador da Cédula de Identidade RG n º 66832910-SP, das penas do artigo 33, caput, da Lei de Drogas e o faço com arrimo no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO RÉU FLAVIO.

Prosseguindo, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA PARA O FIM DE CONDENAR O RÉU MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, filho de Benjamin Aparecido dos Santos e Neuzeli Machado Santos, portador da Cédula de Identidade RG n º 56.996.657, natural de Santa Isabel-SP a PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE correspondente 05 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO e O PAGAMENTO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo existente na época dos fatos, devidamente corrigido, à míngua de maiores dados sobre a situação econômica do sentenciado, por subsumir-se ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n º 11343/2006.

Com relação ao direito do réu MARCOS apelar em liberdade, entendo não ser o caso de concessão desse direito, pois não há a menor dúvida de que o ilícito em questão é sabidamente grave e pernicioso, provocando o aumento da violência e intranquilidade social, causando evidente clamor público, onde elegem a venda de droga como meio de vida e forma de obtenção de dinheiro fácil certamente, em face de reincidência retratada na Folha de Antecedente, galgando novamente a liberdade retornará à mercancia e deixará novamente em risco à sociedade.

De igual forma não é possível convolar a prisão preventiva em domiciliar, pois a prisão preventiva ora mantida pauta-se na premente necessidade de manutenção da ordem pública.

Não se desconhece da pandemia viral (COVID 19), mas a gravidade concreta dos fatos já analisados recomenda a manutenção da prisão ante o risco concreto de reiteração delitiva não se demonstrando recomendável a adoção, por ora, de medidas cautelares diversas da prisão.

Reforce-se, ainda, somada à não comprovação de qualquer uma das hipóteses da Resolução n º 62 do CNJ, deixando a defesa de comprovar doença grave ou outra circunstância a autorizar a prisão domiciliar, medidas preventivas necessárias estão sendo implementadas com o intuito de evitar o contágio em estabelecimentos penais.

Frise-se, também, que o Réu MARCOS encontra-se preso desde o início da instrução e, uma vez sentenciado o feito, deverá permanecer preso, onde a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, prisão cautelar por natureza, não se caracteriza como pena antecipada.

Neste caminhar recomenda-se o Réu MARCOS na prisão em que se encontra.

Independentemente do trânsito em julgado, expeça-se guia em relação ao réu MARCOS.

Após o trânsito em julgado, mantidas as condenações, lance-se o nome do réu MARCOS no rol dos culpados e suspendam-se os direitos políticos do sentenciado enquanto perdurar os efeitos da condenação criminal (artigo 15, inciso III, da Constituição

Federal).

Determino a incineração da droga e o perdimento dos bens em favor da União.

Expeça-se Certidão de honorários em favor da nobre advogada que patrocinou os interesses do acusado FLAVIO.

Por fim, certifique a serventia se o mandado de prisão foi devidamente cumprido, cobrando-o em caso negativo.

Custas de acordo com a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se

Santa Isabel, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA